

1500488-38.2021.8.26.0035

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GISELA AGUIAR WANDERLEY

Comarca: Águas de Lindóia

Foro: Foro de Águas de Lindóia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... acusado concorreu para a prática do tráfico de drogas.

Registre-se que a circunstância de o acusado ser usuário de drogas e de exercer trabalho lícito não afastam por completo a possibilidade de, paralela e concomitantemente, concorrer para o tráfico de drogas.

Quanto à tipicidade, cumpre notar que o crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo (ação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Águas de Lindóia

Foro de Águas de Lindóia

Vara Única

Rua Francisco Spartani, 66., Águas de Lindóia - SP - cep 13940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500488-38.2021.8.26.0035 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500488-38.2021.8.26.0035

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL SILVERIO PEREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GISELA AGUIAR WANDERLEY

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP) em face de DANIEL SILVERIO PEREIRA, na qual lhe é imputada a prática de infração penal (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06).

Narra-se na denúncia, em resumo, que "no dia 26 de novembro de 2021, por volta da 0h20min, na Rua Domingos Lazari, no município de Lindóia, DANIEL SILVERIO PEREIRA trazia consigo, para fins de consumo de terceiros, 3 porções de maconha, pesando cerca de 14,35g, e 34 pedras de crack, pesando em torno de 11,4g, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, auto de constatação provisória de fls. 12/13 e laudo toxicológico a ser oportunamente juntado". (fls. 74/76).

A denúncia foi recebida em 01/03/2022.

Promovida a notificação (fls. 111), DANIEL SILVERIO PEREIRA apresentou defesa prévia (fls. 84/88).

Não constatada hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 397), designou-se audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida a prova oral requerida pelas partes e, após, procedeu-se ao interrogatório.

Não houve requerimento de diligências complementares (CPP, art. 402).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação e a defesa a absolvição. Subsidiariamente, requereu a desclassificação, a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Trata-se de ação penal pública na qual veiculada imputação da prática de infração penal, à luz do artigo 33, caput, da Lei nº11.343/06 e.

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo laudo de exame pericial (químico-toxicológico entorpecentes) - fls. 117/122), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, conforme ata e mídia. Constam dos autos, ainda, os seguintes elementos probatórios: laudo de exame pericial - Objeto - anotações (fls. 123/129); auto de apreensão (fls.10/11).

Quanto à autoria, é importante sumarizar o teor dos depoimentos colhidos.

A testemunha Vagner de Oliveira Preto (policial civil) relatou que a prisão do acusado foi realizada em uma operação feita no bairro Casas Populares, também próximo à quadra, de dia e de noite também; que nesse dia por volta da meia noite fizeram campana e visualizaram Daniel, que já havia sido preso alguns meses antes, realizando a venda a um motociclista e em seguida foram ao local, o motociclista já tinha saído do local e conseguiram abordá-lo; que ele tinha dinheiro, maconha e crack; que ele confessou que realmente estava vendendo e também era usuário; que o conduziram com apoio da PM à delegacia, onde foi ratificada a prisão em flagrante; que estavam monitorando de longe e assim que viram pessoa que foi adquirir as drogas, foi o momento em que fizeram a abordagem; que ele estava sozinho na rua em frente à quadra; que ele ficava andando, acha que pelo quarteirão, por ali, no intuito de captar os compradores que já sabiam dessa característica; que ele ficava andando por ali para poder localizar os clientes; que também efetuou a prisão dele no caso anterior; que ele morava naquele bairro e era comum ele estar por lá, próximo a locais de tráfico, inclusive foi preso alguns meses antes por fato da mesma natureza; que não se recorda se foi ele que efetuou a abordagem que resultou na prisão, pois fez várias abordagens; que encontraram R\$ 45, 3 porções de maconha e 34 de crack; que não abordaram o motociclista com quem o acusado fez a negociação; que o acusado confessou que estava traficando e que também era usuário; que ratifica o termo de depoimento que assinou.

A testemunha Cassiano Aparecido França de Lima relatou que estavam em operação de combate ao tráfico quando se depararam com Daniel próximo à quadra; que uma moto assim que viu a aproximação da viatura se evadiu; que abordaram o acusado, ficaram surpresos porque ele já tinha sido abordado alguns dias antes por tráfico; que localizaram droga, dinheiro, anotações de venda; que já o conhecia dos meios policiais, já foi abordado diversas vezes; que no dia da prisão anterior ele tentou fugir da PM e conseguiram detê-lo com uma quantia boa de droga, mas nesse dia ele não esboçou reação nenhuma; que ele estava caminhando sozinho; que em outra abordagem a ele, não havia nada com ele, mas ele é constantemente visto próximo aos pontos de venda de entorpecente, e inclusive a PM o prendeu uma semana antes na traficância; que localizaram R\$ 45, mais de trinta pedras de crack, maconha e anotações com nomes de pessoas já conhecidas no meio do tráfico; que eram papéis dobrados; que ele confessou; que ratifica o termo de depoimento; que não consta do termo a confissão porque não tinham como provar.

Por fim, o acusado Daniel Silverio Pereira relatou que foi buscar o crack, estava realmente com R\$ 45 e parou um motociclista e falou "Daniel, não quer ganhar 2 pedras de crack?"; que disse que queria sim; que ele então pediu para passar a limpo algumas anotações e entregar para alguém da biqueira; que fez as anotações e ficou esperando, mas não apareceu ninguém; que subiu e não achou ninguém; que saiu e voltou de novo, mas não para a quadra; que voltou no sentido da sua casa, e foi

quando o abordaram e acharam as anotações e o alvará; que foram à sua casa, abriram o portão, invadiram para dentro de casa e saíram com essas 34 pedras de crack e maconha; que eles disseram que se ele não confessasse iriam dar um tiro no pé dele e levá-lo preso; que disse que a droga era dele, mas não era; que estavam na casa ele e seu irmão Miron; que Miron estava dormindo e não viu os policiais; que não sabe de onde veio a droga; que ia passar a limpo as anotações, colocando as datas certinho; que só conhece o motociclista pelo apelido, Porcão; que as drogas seriam dadas por Porcão, e era para o destinatário das anotações; que mora só com seu irmão; que consome crack e maconha; que consome de 25 a 30 pedras de crack por dia; que desceu para ir buscar pedras de crack, ia buscar 4 pedras e Porcão ofereceu 2 pedras.

Verifica-se, pois, que o depoimento dos policiais é uníssono quanto à abordagem do acusado e quanto à apreensão da droga em sua posse, bem assim das anotações indicativas de tráfico. Com efeito, relataram ambos que o acusado foi surpreendido após negociação com um motociclista que se evadiu ao visualizar a viatura policial e que em revista foram localizadas drogas com o acusado. As pequenas contradições indicadas pela defesa técnica são de menor relevância e não são suficientes para infirmar a credibilidade do relato.

De outro lado, observa-se que foi ventilada em defesa a tese de negativa de autoria, a qual, porém, está desprovida de elementos que lhe confirmem aceitabilidade e verossimilhança e acaba se revelando divorciada das demais provas produzidas, as quais confirmam de modo íntegro e coerente a hipótese acusatória. A saber, verifica-se que não há coerência interna da própria narrativa, tampouco coerência externa com os demais elementos probatórios trazidos aos autos. Com efeito, não ostenta mínima plausibilidade a hipótese de a polícia, a partir de suposta viatura caracterizada, ter visualizado a negociação do acusado com o motociclista e, mesmo assim, não ter abordado o acusado. A tese de flagrante forjado não se sustenta. O próprio acusado alega que esperou por cerca de quarenta minutos e ainda se deslocou até outra “biqueira” até encontrar o suposto destinatário das anotações de tráfico que iria – sem motivo algum – “passar a limpo”. O laudo pericial de fls. 123-129 não se coaduna com a versão do acusado no sentido de que teria passado as informações em folhas esparsas com “as datas certinho” para uma folha só. As anotações estão em folhas esparsas e não há indicação precisa de datas. Não é plausível que um traficante peça a um usuário no meio da rua para passar a limpo as anotações. Ademais, não há razão para a polícia visualizar o contato entre o acusado e o suposto traficante, aguardar substancial lapso temporal (quarenta minutos) e ainda deixar o acusado se deslocar de biqueira para só depois abordá-lo e forjar drogas contra si, inclusive depois de invadir a sua residência. O seu irmão Miron estaria na residência e, de acordo com o acusado, não teria visto a polícia invadir o imóvel, só tendo sido informado da prisão do acusado depois, pelos próprios policiais (que, no entanto, de acordo com o acusado, estariam forjando drogas contra si, situação em que não teriam razão alguma para avisar o fato ao seu irmão). Vê-se então que a tese deduzida em autodefesa foi apresentada em caráter ad hoc, com o objetivo de cominar de nula a intervenção policial, e está totalmente divorciada dos demais elementos probatórios.

Quanto ao valor probatório a ser conferido ao depoimento dos policiais que atuaram na repressão imediata à infração penal, é oportuno obtemperar que tal atuação na fase de investigação não implica óbice à oitiva de tais agentes públicos na instrução processual (STF, RHC 108/586, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 9/8/2011).

Assim, as declarações do policial (ou de outros agentes públicos) têm natureza de depoimento testemunhal e, por conseguinte, devem ser valoradas à luz de sua capacidade para depor e da ausência de causas de impedimento ou suspeição. O cargo público ocupado, por si só, não confere maior ou menor valor probatório ao depoimento prestado em juízo. Assim, é indispensável verificar a sua coesão interna e a sua coerência externa com os demais elementos probatórios colhidos no curso da persecução penal, a fim de sopesar o valor probatório que lhe deve ser atribuído. Portanto, em suma, “os depoimentos de policiais devem ser analisados sob o mesmo prisma de qualquer outra testemunha, não tendo seu valor diferenciado pelo fato de

serem servidores públicos" (TJSP; Apelação Criminal 1502002-10.2019.8.26.0548; Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci; 16ª Câmara de Direito Criminal; j. 27/04/2020), e é necessário observar o "seu teor como a qualquer outra testemunha ouvida nos autos, desde que não contrariada por outros elementos de prova" (TJSP; Apelação Criminal 1500121-45.2020.8.26.0618; Rel. Des. Camargo Aranha Filho; 16ª Câmara de Direito Criminal; j. 20/04/2021).

No mesmo sentido se inclina a jurisprudência de ambas as Turmas que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (com competência para julgamento de matéria penal e processual penal): STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2/2/2016; STJ, HC 166979/SP. Min. Rel. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15.08.2012).

Assim, o resultado conjunto das provas coletadas durante a instrução processual é suficiente considerar que o acusado concorreu para a prática do tráfico de drogas. Registre-se que a circunstância de o acusado ser usuário de drogas e de exercer trabalho lícito não afastam por completo a possibilidade de, paralela e concomitantemente, concorrer para o tráfico de drogas.

Quanto à tipicidade, cumpre notar que o crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo (ação múltipla) e pode ser consumado por meio da execução de um dos 18 (dezoito) núcleos do tipo constantes do art. 33 da Lei n. 11.343/06, alguns dos quais de natureza instantânea e outros de natureza permanente. Muito embora a comercialização da droga não seja a única conduta tipificada no referido tipo misto, é preciso reconhecer que o aludido crime possui um elemento implícito, qual seja, a destinação da droga (objeto material do crime) à comercialização ilícita, notadamente ante o cotejo entre tal tipo penal e aqueles tipificados nos arts. 28 (tipo caracterizado pela destinação da droga ao uso próprio) e art. 33, § 3º, da mesma lei (tipo caracterizado pela destinação da droga ao consumo conjunto e gratuito). O que caracteriza o tráfico é a vontade de os agentes verem a droga transferida ou colocada na posse de usuários (entrega ao consumo), traduzida em qualquer um dos dezoito verbos da descrição típica, entre estes, o de transportar, como no caso dos autos.

Assim, a execução isolada e independente de qualquer das dezoito condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, desde que orientada à comercialização ilícita da droga, configura o crime de tráfico de drogas.

No caso, inviável a desclassificação requerida. A variedade de drogas e as anotações apreendidas são incompatíveis com a tese de destinação para consumo próprio.

A tipicidade da conduta, por força da teoria da indiciabilidade (*ratio cognoscendi*) acarreta a presunção (relativa) de sua ilicitude. Esta, por sua vez, não foi afastada pela demonstração de circunstâncias aptas a gerar dúvida razoável quanto à configuração de qualquer excludente (legal ou supralegal) de ilicitude. De outro lado, quanto à culpabilidade, observa-se que o agente é imputável e que não estão demonstradas causas de exclusão do potencial conhecimento da ilicitude do fato ou da exigibilidade de conduta diversa. Assim, não foram comprovadas causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

Assim, constata-se que o acusado praticou conduta típica e ilícita pela qual é culpável, de modo que, preenchidos os três estratos do conceito analítico de crime, mostra-se imperativa a condenação penal.

Passa-se então à aplicação da pena, com base nas diretrizes constantes dos arts. 59 e 68 do CP e do art. 42 da Lei n. 11.343/06, à luz do princípio da individualização das penas (CR/88, art. 5º, XLVI).

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, a certidão de antecedentes demonstra a existência de uma condenação penal definitiva (cf. Súmula 444/STJ), a qual também configura reincidência (CP, art. 64). Assim, a fim de evitar punição dúplice pelo mesmo fato (*bis in idem*), tal registro negativo será considerado apenas como reincidência na segunda fase, sem produzir efeito nesta primeira fase (cf. Súmula 241/STJ). Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração

penal não transbordam o ordinário à espécie. Por fim, em relação ao comportamento da vítima, esta não contribuiu para a prática do crime.

Quanto às circunstâncias preponderantes previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06 ainda não analisadas (natureza e quantidade da droga), devem ser valoradas negativamente. Quanto à natureza da droga (crack), trata-se de substância com elevado potencial nocivo à saúde e alto grau de dependência, o que deve ser valorado negativamente nesta fase da dosimetria. Quanto à quantidade de droga, verifica-se que não houve a apreensão de montante elevado de substância ilícita suficiente para a elevação da pena-base acima do patamar mínimo legal.

Ante tais considerações, fixa-se a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão, mais 625 dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes nem agravantes.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição nem de aumento de pena, razão pela qual a pena definitiva deve ser mantida no patamar da pena provisória.

Quanto à minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), a despeito de se tratar de réu primário e de bons antecedentes, no caso há demonstração de sua dedicação a atividades criminosas. Com efeito, o acusado havia sido preso pelo mesmo delito (tráfico) no mês anterior (22.10.2021), o que já indica a sua dedicação habitual ao tráfico, tendo em vista que, mesmo após a concessão de liberdade provisória, retornou ao exercício da mesma atividade ilícita. De outro lado, a posse de anotações relacionadas ao tráfico também evidencia não se tratar de traficante ocasional.

Por tais razões, fixa-se a pena definitiva em 6 anos e 3 meses de reclusão, mais 625 dias-multa.

Quanto ao valor do dia-multa, à luz dos arts. 49, § 1º, e 60 do CP, deve ser fixado no seu grau mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente quando do pagamento, já que, ao que consta dos autos, o réu não auferia renda superior a um salário mínimo. A pena deve atualizada pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática do TJSP, até o efetivo pagamento.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ante o quantum da pena privativa de liberdade, a primariedade do agente e as circunstâncias judiciais supra valoradas, fixa-se o regime inicial de cumprimento como o regime semiaberto, com base no art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do CP e observadas as Súmulas 718 e 719/STF e 269 e 440/STJ.

Quanto à detração, em atenção ao art. 387, § 2º, do CPP, verifica-se que foi decretada a prisão cautelar do acusado no curso da persecução penal. Contudo, o lapso não interfere na fixação do regime inicial, pois mesmo decotado o período de prisão preventiva da pena aplicada, o regime aplicado continuaria sendo impositivo, em razão da reincidência, diante do supracitado art. 33, § 2º, do CP. Sobre o tema: STJ, AgRg no REsp 1894347/SP, Rel. Ministro Sexta Turma, DJe 10/12/2020; STJ, AgRg no HC 567.813/SP, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020.

Ademais, o lapso de prisão cautelar no caso não deve interferir na fixação do regime, tendo em vista que não ultrapassa o lapso temporal exigido como requisito objetivo para a progressão de regime, determinado pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP), e não há elementos nos autos que permitam a aferição do requisito subjetivo imposto para a concessão do aludido direito. A aferição do cabimento da progressão de regime deve, pois, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, nos autos da execução.

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I) e à suspensão condicional da pena – sursis penal – (CP, art. 77), são incabíveis, tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade aplicada.

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de CONDENAR o acusado DANIEL SILVEIRO PEREIRA ao cumprimento de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 625 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em razão da prática da infração penal descrita no art. 33 da Lei n. 11.343/06, c/c art. 61, I, do CP.

Quanto à manutenção prisão cautelar, à luz do art. 387, § 1º, do CPP, cumpre notar que as razões já esposadas para a sua decretação permanecem presentes. A saber, com

a prolação desta sentença foi ratificado o requisito da fumaça do cometimento do delito, ao passo que nenhum fato superveniente à aludida decisão afastou ou mesmo mitigou o perigo advindo da colocação do acusado em liberdade já antes verificado. Por tais razões, impõe-se a manutenção da prisão preventiva do acusado. Recomende-se ré o réu na prisão em que se encontra.

Não obstante, expeça-se guia provisória de execução penal, em atenção ao que determina a Súmula 716/STF, a fim de que sejam implementadas as condições do regime ora imposto (STF, HC 180957, Segunda Turma, DJe 13.05.2020, RHC 166279/SP, Segunda Turma, DJe 2.2.2020; HC 123267, Primeira Turma, DJe 02.02.2015; STF, HC 118528, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 14.02.2014), tal como admitido também pelo STJ (RHC 12.561/GO, Quinta Turma, DJe 29.06.2020, RHC 75.051/MG, Sexta Turma, DJe 16.12.2016), salvo se da unificação de penas resultar a imposição de regime mais gravoso pelo Juízo da execução penal (LEP, art. 111, parágrafo único). Quanto à arma de fogo e às munições apreendidas, deve ser decretada a perda em favor da União. Encaminhem-se ao Comando do Exército para destruição, nos termos do art. 25 da Lei n. 10.826/03.

Quanto à droga apreendida, deve ser promovida a destruição das amostras eventualmente acauteladas, caso ainda não tenha sido realizada, na forma do art. 72 da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao dinheiro apreendido, deve ser decretada a sua perda em favor do FUNAD (LAD, art. 63) na forma do art. 516, caput e §§ 1º a 5º das NSCGJ.

Quanto à multa, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, intime-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 686), sem prejuízo da expedição de guia definitiva quanto à pena privativa de liberdade e da intimação para pagamento das custas (NSCGJ/SP, art. 480, caput e § 1º). Recolhida a multa, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (NSCGJ/SP, art. 480, § 2º).

Não sendo promovido o pagamento, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ/SP.

Custas pelo réu (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Águas de Lindoia, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA